

문1.

1. 문제의 소재(쟁점) : 기판력의 객관적 범위, 상계항변에 제공된 채권에 대하여 기판력이 인정되는 범위 - 2점
2. 기판력의 객관적 범위 - 7점
 - 판결주문에서 한 판단에 한하여 기판력이 인정되며(제216조 제1항), 판결이유 중의 항변사항에 대해서는 그것이 판결주문의 결론을 내리는 기초가 되었다 하더라도 기판력이 생기지 않음
 - 다만 상계항변은 예외. 피고가 상계항변을 제출하고 법원이 자동채권의 존부에 관하여 판결이유에서 판단하였을 경우에는 상계로써 대항한 액수의 한도 내에서 기판력이 발생함(제216조 제2항).
 - 판결이유 중의 판단임에도 상계 주장에 관한 법원의 판단에 기판력을 인정한 취지
3. 상계항변의 경우 기판력의 인정 범위 - 8점
 - 자동채권의 존부에 관하여 실질적인 판단이 있었을 것
: 상계항변의 실기각하, 상계금지, 상계부적상 등의 이유로 상계항변이 배척된 경우에는 기판력이 발생하지 않음. 상계로써 대항한 액수에 한하여 기판력 발생
 - 수동채권이 소송물로서 심판의 대상일 것
: 대법원 2005. 7. 22. 선고 2004다17207 판결의 결론 및 취지
4. 사안에의 적용 및 결론 - 3점
 - 갑 주장의 대여금채권의 부존재에 기판력 발생하지 않으므로 후소에서 이와 다른 주장 가능, 따라서 갑의 후소에서의 청구가 전소 확정판결의 기판력에 저촉된다는 을의 항변은 타당하지 않음
(그러나 전소확정판결이유에서 판단된 위 대여금채권 부존재 사실이 후소에서 이를 채용할 수 없는 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되므로, 후소법원은 특별한 사정이 없는 한 청구 기각판결을 해야 할 것임)

문2.

- I. 문제의 제기 (보너스 점수 3점)

문서가 증거로 제출된 경우 그에 대한 증거조사절차로서 먼저 문서에 대한 성립의 인부절차를 진행, 이에 대한 상대방의 답변태도로서 성립인정(자백), 침묵, 부인, 부지 등이 있는데 이에 대한 소송절차상의 취급이 각기 다르다.

II. 문2 (1)항의 해결

1. 문서의 형식적 증거력의 의의 (10점)

(1) 공문서와 사문서, 처분문서와 보고문서의 구별의 필요성 - 변제영수증은 사문서로서 처분문서임. 처분문서에 대한 형식적 증거력과 실질적 증거력에 대해서도 언급할 필요가 있음.

(2) 위 영수증의 형식적 증거력 - 민소법 제358조의 해석론 (10점)

인영부분은 인정하되 날인사실을 부인한 경우, 판례는 이른바 2단의 추정이론을 정립. 따라서 갑이 자신의 인장이 도용된 사실(도용사실) 또는 모용사실을 증명하지 못하는 이상 영수증의 진정 성립은 추정되어 인정된다.

2..문서의 실질적 증거력의 의의 (10점)

(1) 처분문서의 경우 형식적 증거력이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상 실질적 증거력이 인정된다.

(2) 위 영수증의 형식적 증거력이 추정되어 인정되므로 갑이 인장의 도용사실을 증명하지 못하면 법원은 특별한 사정이 없는 이상 영수증의 실질적 증거력을 인정하여야 한다. 즉 법원은 갑이 도용사실을 증명하지 못하면 특별한 사정이 없는 이상 영수증에 기재되어 있는 사실 즉 을이 갑에게 변제한 사실을 인정하여야 한다.

III. 문2 (2)항의 해결

1. 문서의 진정성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 것이지만 이에 대하여 재판상 자백과 같은 구속력이 인정되는가. 판례의 입장은 무엇인가.(5점)

2. 문서의 진정성립에 관한 자백을 하였다가 위조주장을 하면서 이를 부인하는 항변을 하는 것이, 즉 이를 취소하는 것이 허용되기 위해서 필요한 요건은? (5점)

문3.

제(1)항에 대한 답안 (10점)

가. 결론(3점)

법원은 무변론 원고 승소판결을 함으로써 사건을 종결시킬 수 있다.

나. 근거 (7점)

민소법 제257조 2항에 따라 피고가 청구원인 사실에 대해 모두 자백하는 취지의 답변서를 제출하고 따라 항변을 하지 않으면 법원은 원고의 주장이 주장자체로 실당한 경우를 제외하고 무변론 원고 승소판결을 할 수 있다.

사안에서 을은 자신이 갑의 승낙 없이 소유권이전등기를 마쳤고 그 등기의 말소청구에 응하겠다는 취지의 답변서를 제출함으로써 원고의 청구원인사실을 모두 자백하였고 따로 항변을 제기하지 않았으므로 법원은 민소법 257조 2항에 의해 무변론 원고 승소판결을 할 수 있다.

제(2)항에 대한 답안. (20점)

1. 문제의 제기

등기의 추정력 : 부동산 등기부상 소유자로 등기되어 있는 자는 특별한 사정이 없는 한 그 부동산의 소유자로 추정된다. 즉 판례에 의하면 등기가 있으면 등기된 권리의 존재 및 귀속, 등기원인의 존재 및 등기절차의 적법성이 법률상 추정된다고 하고 있다. (5점)

2. 사안의 해결

1) 이와 같이 법률상 추정의 경우에는 상대방이 추정된 사실에 반하는 반대사실에 대한 증명책임을 진다. 즉 추정된 사실을 깨뜨리려면 반증으로 족한 것이 아니라 반대사실의 존재에 대하여 법관에게 확신을 주어야만 한다. 따라서 현 등기명의인인 피고 을이 갑의 대리인 A에 의한 계약체결사실을 주장한 경우에 전 소유명의인인 갑은 그 반대사실 즉 A에게 갑을 대리할 권한이 없었다든가 또는 A가 갑의 등기관계서류를 위조하였다는 등의 원인무효사실에 대한 증명책임을 진다. (10점)

2) 따라서 사안의 경우 법원이 심리한 결과 A에 대한 대리권 수여 여부가 진위불명이 되어 버렸으므로(즉 법원이 A에게 대리권이 수여되지 않았다는 사실에 대하여 확신을 갖지 못하게 되었으므로) 법원은 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하여

야 한다.(5점)

제(3)항에 대한 답안 (20점)

1. 문제의 소재(2점)

병과 정은 피고 을의 공동상속인이고 상속재산은 공유재산으로서 그 관리처분권을 공동으로 행사하는 것이 실체법상 강제되는 관계에 있지 않으므로 병과 정의 공동소송형태는 통상공동소송이다. 이에는 민소법 66조 소정의 공동소송인독립의 원칙이 적용된다. 그러나 이를 그대로 관철할 경우 공동소송인들 간에 모순, 저촉되는 판단이 초래되는 상황이 생길 수 있는데 이를 시정하는 원리로서 공동소송인들 간에 주장공통의 원칙을 인정할 것인가가 문제 된다.

2. 주장공통의 원칙의 의의(5점)

- 공동소송인 중 1인이 상대방의 주장사실을 다투는 등 다른 공동소송인에게 유리한 소송행위를 할 때 다른 공동소송인의 원용이 없더라도 그에 대한 효력이 미친다는 원칙.

3. 인정여부(3점)

인정설(긍정설) : 이를 부정하면 역사적 사실은 하나 밖에 있을 수 없다는 논리의 거역, 재판불신의 원인이 된다.

- 불인정설(부정설): 이를 인정하면 변론주의에 정면으로 배치됨.

판례는 부정설의 입장임.

4.. 결론(10점)

병은 갑이 주장하는 청구원인사실에 대해 자백하고 정은 부인하고 있다. 위 인정설에 의하면 정의 부인진술에 따른 효력이 병에게도 그대로 생기는 것으로 보아야 하고, 위 부정설에 의하면 효력이 정의 부인진술에 따른 효력이 병에게 그대로 생기지 않으므로 법원은 병에 대한 소송관계에 있어서 정의 부인진술에도 불구하고 자백한 그대로 사실을 인정하여야 한다. 한편 정에 대한 소송관계에 있어서는 병의 자백이 있었다라도 자백의 효력은 생기지 않고 법원은 이를 단지 변론전체의 취지로 참작할 수 있다. (참조판결 1992.12.11.선고 92다18627판결, 1997.2.28.선고 96다53789판결)